APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016370-56.2015.4.04.9999/SC

RELATORA	:	**Des. Federal VÂNIA HACK DE ALMEIDA**
APELANTE	:	**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**
ADVOGADO	:	**Procuradoria Regional da PFE-INSS**
APELADO	:	**ADELINA DOS SANTOS TOIGO**
ADVOGADO	:	**Daiane Kessler Marques e outros**
	:	**Fernando Augusto de Souza de Lima**

D.E.

Publicado em 22/01/2016

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. **REVISÃO** DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RENDA MENSAL INICIAL. ARTIGO **29**, II, DA LEI Nº 8.213/91. CARÊNCIA DE AÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. A **revisão** administrativa do benefício em momento posterior à DIB, amparada em decisão provisória proferida em ACP, não retira o **interesse** de **agir** da segurada de ingressar com ação individual para buscar a consolidação do seu direito e o pagamento das parcelas atrasadas, cabendo assegurar-se, entretanto, o direito à dedução, pelo INSS, das parcelas porventura recebidas administrativamente.

2. O Memorando-Circular Conjunto nº 21/DIRBEN/PFEINSS, de 15.04.2010, constitui marco interruptivo do prazo prescricional para a **revisão** dos benefícios com base no artigo **29**, II, da Lei 8.213/91. Essa interrupção garante o recebimento das parcelas anteriores a cinco anos da publicação do normativo para pedidos que ingressarem administrativa ou judicialmente em até cinco anos após a mesma data, uma vez que houve reconhecimento administrativo do direito.

3. Para os benefícios por incapacidade concedidos após a vigência da Lei nº 9.876/99 o salário-de-benefício consistirá na média dos maiores salários de contribuição correspondentes a oitenta por cento do período contributivo.

4. As prestações em atraso serão corrigidas pelos índices oficiais, desde o vencimento de cada parcela, ressalvada a prescrição quinquenal, e, segundo sinalizam as mais recentes decisões do STF, a partir de 30/06/2009, deve-se aplicar o critério de atualização estabelecido no **art.** 1º-F da Lei 9.494/97, na redação da lei 11.960/2009.

5. Este entendimento não obsta a que o juízo de execução observe, quando da liquidação e atualização das condenações impostas ao INSS, o que vier a ser decidido pelo STF em regime de repercussão geral (RE 870.947), bem como eventual regramento de transição que sobrevenha em sede de modulação de efeitos.

6. Os juros de mora são devidos a contar da citação, à razão de 1% ao mês (Súmula nº 204 do STJ e Súmula 75 desta Corte) e, desde 01/07/2009 (Lei nº 11.960/2009), passam a ser calculados com base na taxa de juros aplicáveis à caderneta de poupança (RESP 1.270.439), sem capitalização.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, por negar provimento ao recurso e à remessa oficial, tida por interposta, e, de oficio, adequar a incidência da correção monetária, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 16 de dezembro de 2015.

Des. Federal VÂNIA HACK DE ALMEIDA
Relatora

Documento eletrônico assinado por **Des. Federal VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Relatora**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **7970976v4** e, se solicitado, do código CRC **63B495B0**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a):	Vânia Hack de Almeida
Data e Hora:	17/12/2015 16:20

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016370-56.2015.4.04.9999/SC

RELATORA	**:**	**Des. Federal VÂNIA HACK DE ALMEIDA**
APELANTE	**:**	**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**
ADVOGADO	**:**	**Procuradoria Regional da PFE-INSS**
APELADO	**:**	**ADELINA DOS SANTOS TOIGO**
ADVOGADO	**:**	**Daiane Kessler Marques e outros**
	:	**Fernando Augusto de Souza de Lima**

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta em face do INSS na qual a parte autora objetiva a **revisão** de seu benefício previdenciário, com DIB em 28/11/2008, a fim de que seja recalculada a renda mensal inicial de acordo com o artigo **29**, inciso II, da Lei nº 8.213/91.

A sentença julgou procedente a ação para o fim de condenar o INSS a recalcular a RMI do benefício previdenciário do autor, realizando o cálculo do salário-benefício com base na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo, com o pagamento das diferenças havidas desde a data da concessão, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios, observada a prescrição quinquenal. Condenou o INSS, ainda, no pagamento de honorários advocatícios e de metade das custas processuais.

Da sentença o INSS interpôs apelação, argüindo a carência de ação por ausência

de **interesse** de **agir**, tendo em vista que já foi procedida a **revisão** administrativa, já existindo p**revisão** de pagamento conforme transação judicial homologada nos autos da Ação Civil Pública nº 00023205920124036183. Requereu, assim, a extinção do processo, sem julgamento do mérito. Alternativamente, requereu seja reconhecida a prescrição qüinqüenal. Prequestionou a matéria para fins recursais.

Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Remessa Oficial

Consoante decisão da Corte Especial do STJ (EREsp nº 934642/PR), em matéria previdenciária, as sentenças proferidas contra o Instituto Nacional do Seguro Social só não estarão sujeitas ao duplo grau obrigatório se a condenação for de valor certo (líquido) inferior a sessenta salários mínimos.

Não sendo esse o caso, tenho por interposta a remessa oficial.

Carência de ação

Não assiste razão ao INSS.

É que o momento para aferição das condições da ação é quando, como regra, o juiz toma contato pela primeira vez com a petição inicial (incluindo seus documentos).

Assim, no momento da propositura da presente ação a parte autora possuía **interesse** processual.

De mais a mais, a r **revisão** administrativa do benefício em momento posterior à DIB, amparada em decisão provisória proferida em ACP, não retira o **interesse** de **agir** da segurada de ingressar com ação individual para buscar a consolidação do seu direito e o pagamento das parcelas atrasadas, cabendo assegurar-se, entretanto, o direito à dedução, pelo INSS, das parcelas porventura recebidas administrativamente.

Por fim, observo que a ação coletiva veicula direitos individuais homogêneos e somente a sua procedência produz coisa julgada de efeito *erga omnes*, que não beneficiará, entretanto, os autores de ações individuais se estes não requererem a suspensão destas no prazo de 30 dias (Lei 8.078/90, arts. 81, III, c/c 103, III, e 104). Ora, se não haverá produção de coisa julgada em tal hipótese, que é a dos autos, também não haverá a de litispendência, não sendo de cogitar-se de ausência de **interesse** de **agir** do autor.

Ressalto que eventuais diferenças já pagas na via administrativa deverão ser levadas em conta nas posteriores fases de liquidação e execução.

Interrupção da prescrição em razão do Memorando-Circular Conjunto nº 21

O Memorando-Circular Conjunto nº 21/DIRBEN/PFEINSS, de 15.04.2010, constitui marco interruptivo do prazo prescricional para a **revisão** dos benefícios com base no artigo **29**, II, da Lei 8.213/91. Essa interrupção garante o recebimento das parcelas anteriores a cinco anos da publicação do normativo para pedidos que ingressarem administrativa ou judicialmente em até cinco anos após a mesma data, uma vez que houve reconhecimento administrativo do direito.

Revisão - artigo 29, inciso II, da Lei 8.213/1991

A Colenda 6ª Turma desta Corte já examinou a questão posta em exame tendo firmado seu posicionamento no sentido de que, nos termos do **art. 29**, II da Lei 8.213/91, o salário de benefício do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez consiste na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever o voto proferido pelo eminente Desemb. Federal João Batista Pinto Silveira que, no julgamento da AC nº 5015928-20.2011.404.7000/PR, datado de 30/01/2013, examinou a matéria nos seguintes termos:

> ***Do pedido de revisão conforme art. 29, II, da Lei 8.213-91***
>
> *O INSS normalmente calcula os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez em conformidade com o que consta no Decreto nº 3.048/1999, o qual dispõe o seguinte em seu **art.** 188-A, § 4º:*
>
> *Nos casos de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez, contando o segurado com salários de contribuição em número inferior a 60% do número de meses decorridos desde a competência julho de 1994 até a data do início do benefício, o salário de benefício corresponderá à soma dos salários de contribuição dividido pelo número de contribuições mensais apurado.*
>
> *Inobstante o entendimento do réu, o normativo regulamentador utilizado como parâmetro para a apuração da RMI do benefício do autor contraria a legislação previdenciária, em especial, o **art. 29**, II, da Lei nº 8.213/91. In verbis:*
>
> > *O salário de benefício consiste:*
> > *I - (...)*
> > *II - para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso I do **art.** 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo.*
>
> *Ocorre que, a Lei nº 9.876/99 estabelece critérios para o cálculo dos benefícios previdenciários:*
>
> > ***Art.** 3º - Para o segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior à data de publicação desta Lei, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social, no cálculo do salário de benefício será considerada a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a, no mínimo, oitenta por cento de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994, observado o disposto nos incisos I e II do*

*§ 6º, do **art. 29**, da Lei n. 8.213/91, com a redação dada por esta Lei.*

Denota-se, assim, que não há legalidade no critério utilizado pelo INSS, que tem como base o Decreto nº 3.048/99.

*Com efeito, para obtenção da RMI dos benefícios previdenciários de auxílio-doença e invalidez, o INSS deve, nos termos da legislação supracitada, realizar a média aritmética simples dos 80% (oitenta por cento) maiores salários de contribuição desde julho de 1994 (**art.** 3º, da Lei nº 9.876/99), desconsiderando os 20% (vinte por cento) menores.*

Desse modo, como a utilização de todos os salários (100%) do auxílio-doença traz evidente prejuízo no valor do benefício do segurado e tendo em vista o que prevê a lei sobre a matéria, merece acolhimento a pretensão.

Neste sentido:

*APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE **REVISÃO** DE RENDA MENSAL INICIAL - BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - CÁLCULO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO REALIZADO PELA AUTARQUIA DE ACORDO COMO O § 2º DO **ART.** 32 DA LEI N. 8.213/91, ACRESCIDO PELO DECRETO N. 5.545/2005 - SOMA DE TODOS OS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO DO PERÍODO CONTRIBUTIVO - OPERAÇÃO INDEVIDA - APLICAÇÃO DO **ART. 29**, II, DA LEI N. 8.213/91 - LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO INFORTÚNIO - MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES DOS MAIORES SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDENTES A OITENTA POR CENTO DE TODO O PERÍODO CONTRIBUTIVO - **REVISÃO** DEFERIDA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS (TJSC, Apelação Cível n. 2007.048567-0, Des. Anselmo Sigilo, Julgado em 29/11/2007).*

Assim, adotando o posicionamento acima como razões de decidir, é de ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de **revisão** da renda mensal inicial com fulcro no **art. 29**, II, da Lei 8.213/91.

Consectários

De início, esclareço que a correção monetária e os juros de mora, sendo consectários da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício (AgRg no AREsp: 144069 SP 2012/0026285-1, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 19-10-12). Assim, sequer há que se falar em *reformatio in pejus*.

A correção monetária, segundo o entendimento consolidado na 3ª Seção deste TRF4, incidirá a contar do vencimento de cada prestação e será calculada pelos índices oficiais e aceitos na jurisprudência, quais sejam:

- ORTN (10/64 a 02/86, Lei nº 4.257/64);
- OTN (03/86 a 01/89, Decreto-Lei nº 2.284/86);
- BTN (02/89 a 02/91, Lei nº 7.777/89);
- INPC (03/91 a 12/92, Lei nº 8.213/91);
- IRSM (01/93 a 02/94, Lei nº 8.542/92);
- URV (03 a 06/94, Lei nº 8.880/94);
- IPC-r (07/94 a 06/95, Lei nº 8.880/94);
- INPC (07/95 a 04/96, MP nº 1.053/95);
- IGP-DI (05/96 a 03/2006, **art.** 10 da Lei n.º 9.711/98, combinado com o **art.** 20, §§5º e 6.º, da Lei n.º 8.880/94);

- INPC (de 04/2006 a 29/06/2009, conforme o **art.** 31 da Lei n.º 10.741/03, combinado com a Lei n.º 11.430/06, precedida da MP n.º 316, de 11/08/2006, que acrescentou o **art.** 41-A à Lei n.º 8.213/91);

- TR (a partir de 30/06/2009, conforme **art.** 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo **art.** 5º da Lei 11.960/2009).

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade por arrastamento do **art.** 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo **art.** 5º da Lei 11.960/2009, afastando a utilização da TR como fator de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, relativamente ao período entre a respectiva inscrição em precatório e o efetivo pagamento.

Em consequência dessa decisão, e tendo presente a sua ratio, a 3ª Seção desta Corte vinha adotando, para fins de atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública, a sistemática anterior à Lei nº 11.960/2009, o que significava, nos termos da legislação então vigente, apurar-se a correção monetária segundo a variação do INPC, salvo no período subsequente à inscrição em precatório, quando se determinava a utilização do IPCA-E.

Entretanto, a questão da constitucionalidade do uso da TR como índice de atualização das condenações judiciais da Fazenda Pública, no período antes da inscrição do débito em precatório, teve sua repercussão geral reconhecida no RE 870.947, e aguarda pronunciamento de mérito do STF. A relevância e a transcendência da matéria foram reconhecidas especialmente em razão das interpretações que vinham ocorrendo nas demais instâncias quanto à abrangência do julgamento nas ADIs 4.357 e 4.425.

Recentemente, em sucessivas reclamações, a Suprema Corte vem afirmando que no julgamento das ADIs em referência a questão constitucional decidida restringiu-se à inaplicabilidade da TR ao período de tramitação dos precatórios, de forma que a decisão de inconstitucionalidade por arrastamento foi limitada à pertinência lógica entre o **art.** 100, § 12, da CRFB e o artigo 1º-F da Lei 9.494/97, na redação dada pelo **art.** 5º da Lei 11.960/2009. Em consequência, as reclamações vêm sendo acolhidas, assegurando-se que, ao menos até que sobrevenha decisão específica do STF, seja aplicada a legislação em referência na atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, salvo após inscrição em precatório. Os pronunciamentos sinalizam, inclusive, para eventual modulação de efeitos, acaso sobrevenha decisão mais ampla quanto à inconstitucionalidade do uso da TR para correção dos débitos judiciais da Fazenda Pública (Rcl 19.050, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 21.147, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 19.095, Rel. Min. Gilmar Mendes).

Em tais condições, com o objetivo de guardar coerência com os mais recentes posicionamentos do STF sobre o tema, e para prevenir a necessidade de futuro sobrestamento dos feitos apenas em razão dos consectários, a melhor solução a ser adotada, por ora, é orientar para aplicação do critério de atualização estabelecido no **art.** 1º-F da Lei 9.494/97, na redação da lei 11.960/2009.

<u>Este entendimento não obsta a que o juízo de execução observe, quando da liquidação e atualização das condenações impostas ao INSS, o que vier a ser decidido pelo STF em regime de repercussão geral, bem como eventual regramento de transição que sobrevenha em sede de modulação de efeitos.</u>

Quanto aos juros de mora, até 29-06-2009, apurados a contar da data da citação, devem ser fixados à taxa de 1% ao mês, com base no **art.** 3º do Decreto-Lei n. 2.322/87, aplicável analogicamente aos benefícios pagos com atraso, tendo em vista o seu caráter eminentemente alimentar, consoante firme entendimento consagrado na jurisprudência do STJ e na Súmula 75 desta Corte.

A partir de então, deve haver incidência dos juros, uma única vez, até o efetivo pagamento do débito, segundo o índice oficial de remuneração básica aplicado à caderneta de poupança, nos termos estabelecidos no **art.** 1º-F, da lei 9.494/97, na redação da Lei 11.960/2009. Os juros devem ser calculados sem capitalização, tendo em vista que o dispositivo determina que os índices devem ser aplicados "uma única vez" e porque a capitalização, no direito brasileiro, pressupõe expressa autorização legal (STJ, 5ª Turma, AgRg no AgRg no Ag 1211604/SP, Rel. Min. Laurita Vaz).

Quanto ao ponto, esta Corte já vinha entendendo que no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 não houvera pronunciamento de inconstitucionalidade sobre o critério de incidência dos juros de mora previsto na legislação em referência.

Esta interpretação foi, agora, chancelada, pois no exame do recurso extraordinário 870.947, o STF reconheceu repercussão geral não apenas à questão constitucional pertinente ao regime de atualização monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública, mas também à controvérsia pertinente aos juros de mora incidentes.

Em tendo havido a citação já sob a vigência das novas normas, inaplicáveis as disposições do Decreto-lei 2.322/87, incidindo apenas os juros da caderneta de poupança, sem capitalização.

De ofício, reforma-se a incidência da correção monetária.

Mantenho os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre as parcelas vencidas até a decisão judicial concessória do benefício previdenciário pleiteado (Súmula nº 76 do TRF4 e nº 111 do STJ).

O INSS é isento do pagamento das custas no Foro Federal (**art.** 4, I, da Lei nº 9.289/96) e na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, devendo, contudo, pagar eventuais despesas processuais, como as relacionadas a correio, publicação de editais e condução de oficiais de justiça (artigo 11 da Lei Estadual nº 8.121/85, com a redação da Lei Estadual nº 13.471/2010, já considerada a inconstitucionalidade formal reconhecida na ADI nº 70038755864 julgada pelo Órgão Especial do TJ/RS), isenções estas que não se aplicam quando demandado na Justiça Estadual do Paraná (Súmula 20 do TRF4), devendo ser ressalvado, ainda, que no Estado de Santa Catarina (**art.** 33, p. único, da Lei Complementar Estadual nº156/97), a autarquia responde pela metade do valor.

Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, não há necessidade de o julgador mencionar os dispositivos legais e constitucionais em que fundamenta sua decisão, tampouco os citados pelas partes, pois o enfrentamento da matéria através do julgamento feito pelo Tribunal justifica o conhecimento de eventual recurso pelos Tribunais Superiores (STJ, EREsp nº

155.621-SP, Corte Especial, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 13-19-99).

Dispositivo

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso e à remessa oficial, tida por interposta, e, de oficio, adequar a incidência da correção monetária, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Federal VÂNIA HACK DE ALMEIDA
Relatora

Documento eletrônico assinado por **Des. Federal VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Relatora**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **7970975v3** e, se solicitado, do código CRC **41982AC9**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a):	Vânia Hack de Almeida
Data e Hora:	17/12/2015 16:20

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO DE 16/12/2015

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016370-56.2015.4.04.9999/SC
ORIGEM: SC 00079753320138240080

RELATOR	:	Des. Federal VÂNIA HACK DE ALMEIDA
PRESIDENTE	:	Desembargadora Federal Vânia Hack de Almeida
PROCURADOR	:	Procuradora Regional da República Adriana Zawada Melo
APELANTE	:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADVOGADO	:	Procuradoria Regional da PFE-INSS
APELADO	:	ADELINA DOS SANTOS TOIGO
ADVOGADO	:	Daiane Kessler Marques e outros
	:	Fernando Augusto de Souza de Lima

Certifico que este processo foi incluído na Pauta do dia 16/12/2015, na seqüência 568, disponibilizada no DE de 02/12/2015, da qual foi intimado(a) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e as demais PROCURADORIAS FEDERAIS.

Certifico que o(a) 6ª TURMA, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, em

sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E À REMESSA OFICIAL, TIDA POR INTERPOSTA, E, DE OFICIO, ADEQUAR A INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

RELATOR ACÓRDÃO	:	Des. Federal VÂNIA HACK DE ALMEIDA
VOTANTE(S)	:	Des. Federal VÂNIA HACK DE ALMEIDA
	:	Juiz Federal OSNI CARDOSO FILHO
	:	Des. Federal JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA

Gilberto Flores do Nascimento
Diretor de Secretaria

Documento eletrônico assinado por **Gilberto Flores do Nascimento, Diretor de Secretaria**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **8057170v1** e, se solicitado, do código CRC **2DDB3122**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a):	Gilberto Flores do Nascimento
Data e Hora:	17/12/2015 19:09